Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent16vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5048508-24.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: ABRAHAO DUQUIA FILHO

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

ABRAHÃO DUQUIA FILHO ajuizou *Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Ressarcimento e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor de* **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.**

O autor informou ser portador de eosinofilia periférica crônica, tratada inicialmente com o medicamento Imatinibe (Glivec), fornecido pelo Estado do Rio Grande do Sul após decisão judicial. Disse que, com o passar do tempo, a eficácia do medicamento diminuiu, levando o autor a uma nova internação, onde foi constatado o aumento perigoso de eosinófilos. Diante disso, os médicos prescreveram o antineoplásico Sprycel (Desatinibe), que apresentou bons resultados. Contudo, o custo elevado do medicamento, cerca de R$ 12.000,00 por caixa, inviabiliza a continuidade do tratamento. Requereu administrativamente à Unimed o fornecimento do medicamento, mas o pedido foi indeferido, sob a alegação de não cumprimento das diretrizes de utilização previstas no Rol de Cobertura da ANS. Sustentou que contrato firmado com a Unimed prevê expressamente a cobertura de medicamentos antineoplásicos domiciliares, conforme a Lei 9.656/98. Ressaltou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Alegou que a negativa de cobertura é indevida, pois a medicação prescrita pela médica assistente é essencial para a manutenção de sua vida. Mencionou já ter desembolsado o valor de R$ 26.414,00 com a compra do medicamento, desde a negativa de fornecimento pela ré, e postulou o ressarcimento desses valores. Em tutela provisória de urgência requereu que a Unimed forneça imediatamente o medicamento *Sprycel*, sob pena de multa e bloqueio de valores. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela e a condenação da ré ao ressarcimento dos valores já gastos.

Recolhidas as custas, foi recebida a inicial e deferido pedido liminar para: *determinar à ré que forneça o medicamento requisitado pela médica e descrito na inicial (Dasatinibe 100mg, via oral, 1x ao dia, continuamente), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em 30 dias* (evento 9, DESPADEC1).

Citada, a ré UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA apresentou contestação sustentando, em síntese, que a negativa de cobertura do medicamento *Desatinibe (Sprycel)*, utilizado no tratamento da Síndrome Hipereosinofílica do autor, foi legítima. Argumentou que, embora o medicamento esteja incluído no Rol da ANS, sua indicação é restrita ao tratamento de leucemia linfocítica aguda e leucemia mielocítica crônica, não havendo comprovação científica de sua eficácia para a condição do autor, conforme Diretriz de Utilização nº 64. Alegou que o Rol da ANS é taxativo e que a cobertura para doenças fora desse rol não é obrigatória, salvo em condições excepcionais, as quais não se aplicam ao caso concreto. Defendeu que as cláusulas contratuais são claras e não abusivas, estando devidamente amparadas pela legislação vigente e pela regulamentação da ANS. Quanto ao pedido de ressarcimento de valores, ressaltou que não há fundamento legal para o reembolso, uma vez que a negativa de cobertura do medicamento foi legítima e contratualmente justificada. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos (evento 25, CONT1).

Houve réplica (evento 28, DOC1).

Instadas, as partes não manifestaram interesse na produção de provas (Eventos 36 e 37).

Sobreveio petição do autor, na qual informa ter sido descontinuado o tratamento com a medicação postulada, pois sofreu um derrame pleural, sendo contra-indicada a manutenção do Desatinibe. Dessa forma, pleiteou a realização de audiência de conciliação, a fim e que as partes possam transacionar sobre o pedido de ressarcimento (evento 40, PET1).

A ré afirmou não possuir interesse em realizar acordo, pois a negativa de fornecimento do medicamente foi legítima (evento 48, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo questões pendentes ou vícios a serem sanados ou mesmo necessidade de produção de provas em audiência, cabível o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.

Trata-se de ação em que a parte autora postulou o deferimento de liminar, de modo a obrigar a ré a fornecer o medicamento requisitado pelo médico e descrito na inicial: *Sprycel* (*Dasatinibe* 100 mg), via oral, 1x ao dia, continuamente. Não há controvérsia acerca da contratação do plano de saúde, tampouco da negativa da ré em fornecer o medicamento extrajudicialmente, assim como de ser o autor portador da moléstia mencionada, sendo que, segundo a médica responsável pelo tratamento (evento 1, LAUDO8):

Paciente vinha em uso há 10 anos de terapia com Imatinibe com excelente resposta para síndrome hipereosinofilia e acidente isquêmico transitório cerebral.
Visto a falha óbvia do Imatinibe, foi feita reavaliação da doença e iniciando Dasatinibe 100 mg via oral ao dia com excelente resposta.
Solicito autorização para uso contínuo de Dasatinibe 100 mg via oral ao dia.

Claudia Caceres Astigarraga
Hematologia e Tmo
CRM 21303 CNPJ: 17.133.049/0001-15

Cinge-se a controvérsia, portanto, sobre a possibilidade de negativa quanto à cobertura do medicamento que necessitava o autor, ao argumento de que o fármaco solicitado não se enquadra no rol de procedimentos da ANS para a patologia do requerente.

Inicialmente, destaca-se que o caso deve ser apreciado levando-se em conta o disposto no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A questão resta pacificada na Súmula nº **469 do STJ:**

"*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.".*

Assim como na Súmula nº **608 do STJ:**

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

No caso em apreço, a Unimed justificou a negativa de cobertura com base na Diretriz de Utilização Técnica nº 64 da ANS, a qual regula o fornecimento de terapias antineoplásicas orais para tratamento do câncer, dispondo de um rol de substâncias ativas cobertas e de um rol de indicações de uso, sendo obrigatória somente a cobertura dos medicamentos listados para as indicações de uso ali constantes, sendo que o medicamento Dasatinibe 100mg solicitado pelo autor não está enquadrado na referida Diretriz.

Ressalto, de plano, que a justificativa apresentada pela Unimed não comporta acolhimento. Embora não desconheça a existência da Resolução estabelecendo critérios objetivos para a cobertura, não se pode esquecer que a medicina não é uma ciência exata, possuindo cada caso clínico as suas peculiaridades e necessidades.

A negativa da Unimed trouxe o seguinte argumento (evento 1, OUT14):

Justificativa

No tocante a solicitação do medicamento **Sprycel (DASATINIBE),** não restou atendida a diretriz de utilização especificadas no Rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 064 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e suas atualizações, e, ainda, conforme a Lei 14454/22, a solicitação não veio acompanhada de documentos comprobatórios de eficácia à luz da ciências da saúde, baseados em evidências científicas e plano terapêutico; ou de recomendações pela CONITEC ou de no mínimo 1 órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e esteja aprovada para seus nacionais, conforme previsto Art. 10 nos parágrafos 12 e 13 da Lei 9.656/98.

Porto Alegre 26 de janeiro de 2023

Cintia Freiri

Ocorre que incumbe ao médico que acompanha o paciente - e não à operadora do plano de saúde - estabelecer qual o melhor tratamento a ser prescrito, de acordo com as peculiaridades da patologia de cada paciente, não sendo dado à operadora do plano de saúde negar a cobertura com base em rol exemplificativo e genérico.

No caso em apreço, resta comprovado que o tratamento postulado se mostrava imprescindível

para o tratamento da doença que acometeu o consumidor, conforme documentos e exames acostados à inicial, em especial o laudo médico, cujo trecho está colacionado nesta decisão, que evidencia a gravidade da doença e ressalta que o tratamento com o medicamento requerido diminui, de forma expressiva, a taxa de recorrência da doença.

Nestes termos, mostra-se inadmissível que a requerida tenha se contraposto à cobertura ao tratamento prescrito ao autor, indispensável para o tratamento da doença que lhe acometia. Ademais, considerando a imprescindibilidade do tratamento naquela época, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, sob pena de consideração como abusiva a cláusula ou interpretação restritiva à luz do artigo 54 do CDC.

Destaco, outrossim, que o autor possui o plano com maior cobertura da Unimed (UNIMAX) sendo esperado pelo consumidor um atendimento mais abrangente, o que faz com que a negativa de cobertura seja abusiva, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, pois em um momento de extrema necessidade teve que arcar com um alto valor (R$ 26.414,00) referente a duas caixas do medicamento ou suportar as consequência da não continuidade do tratamento, o que afigura indevida a recusa da operadora.

Ademais, depois da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negar a cobertura ao tratamento indispensável à parte autora. Existe dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir, de forma ampla, todos os procedimentos, medicamentos e intervenções úteis ou necessárias à manutenção da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças.

No caso dos autos, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS, a qual não pode excluir ou mitigar as hipóteses previstas na Lei dos Planos de Saúde:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,* ***respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:***
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
>
> *Transcreve-se o mencionado art. 12, grifando-se na parte em que se aplica à situação examinada:*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *[...]*
>
> c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;
>
> g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral*, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*

Somado a isso, com relação a taxatividade do Rol de Procedimentos publicado pela ANS, deve ser levado em consideração que a Lei nº 9.656/98 foi alterada pela Lei nº 14.454/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios, conforme segue:

> *Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.*
>
> *Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:*
>
> *"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). (...)*
>
> *4º A* ***amplitude das coberturas*** *no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade,* ***será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar,*** *atualizado a cada incorporação.*
>
> *§ 12.* ***O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica*** *para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> *§ 13.* ***Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde,*** *desde que:*

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

Nesse sentido, corroborando o acima exposto, de que o rol de critérios para a cobertura de procedimentos/medicamentos previstos pela ANS é apenas exemplificativo, cabendo ao médico estabelecer qual o procedimento mais adequado ao caso, são os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. *MEDICAMENTO* ANTINEOPLÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAZOPANIBE (VOTRIENT). *NEOPLASIA* MALIGNA TIPO LEIOMIOSSARCOMA DE ORIGEM UTERINA COM RECIDIVADA EM PULMÕES E ABDÔMEN. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VERIFICADOS. NO CASO CONCRETO, DEMONSTRADO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA O RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. **DESCABIDA A NEGATIVA DE *FORNECIMENTO*, POIS INCUMBE AO *MÉDICO* PRESCREVER O TRATAMENTO. DIREITO AMPARADO NO ART. 12, I, "C", DA LEI N° 9.656/98 QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS *DOMICILIARES* DE USO ORAL COMO PROCEDIMENTO DE COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE**. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50288633120248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 24-04-2024).

Ademais, é entendimento do STJ que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que receberão cobertura, mas não o tipo de tratamento, o qual é de competência do médico que acompanha o paciente, consoante se extrai do voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

> *"A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde.* ***De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.*** *Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02)".*

Destarte, era dever da demandada fornecer o tratamento pleiteado, enquanto necessário, sem a necessidade de intervenção judicial, sendo a procedência do pedido de ressarcimento dos valores das duas caixas adquiridas desde a negativa da Unimed (em 26 de janeiro de 2023) até o deferimento da liminar, medida que se impõe.

Assim, deverá a ré restituir ao autor o valor de R$ 13.099,00, referente à caixa adquirida em fevereiro (evento 1, NFISCAL18) e o valor de R$ 13.315,00, referente à caixa adquirida em março (evento 1, NFISCAL19), corrigidos pelo IGP-M, a contar do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

DIANTE DO EXPOSTO, e para fins do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **ABRAHÃO DUQUIA FILHO** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** para reconhecendo a obrigação da ré quanto ao fornecimento, à época, do medicamento *Dasatinibe 100mg* ao autor, condená-la ao ressarcimento do valor de R$ 13.099,00, referente à caixa adquirida em fevereiro/2023 e o valor de R$ 13.315,00, referente à caixa adquirida em março/2023, corrigidos pelo IGP-M, a contar do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Revogo a liminar, diante da desnecessidade de continuidade do tratamento com a medicação.

Sucumbente, arcará a ré com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2°, do CPC.

Publicada, registrada e intimadas as partes via sistema.

Sobrevindo recurso(s) de embargos de declaração, dê-se vista à parte oposta, por cinco dias. Depois, voltem para análise.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) apelada(s) para, em quinze dias, apresentar(em) contrarrazões. Caso haja recurso adesivo ou suscitação de questões preliminares (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil) em contrarrazões, dê-se vista ao(s) apelante(s) por novos quinze dias, para manifestação.

Concluídas as intimações e decorridos os prazos, remeta-se o feito ao E.Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se pelo lançamento do correspondente movimento no sistema Eproc.

Verifiquem-se as custas finais.

Após, nada mais sendo requerido, e não subsistindo pendências, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **GEOVANNA ROSA, Juíza de Direito**, em 27/9/2024, às 18:29:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10068608822v9** e o código CRC **ded6f52b**.